

RECURSO CÍVEL Nº 5073077-45.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: ELIETE MOREIRA SALAZAR AYRES (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)
RECORRENTE: FRANKLIN ROOSEVELT SALAZAR AYRES (REPRESENTANTE) (AUTOR)
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CIRURGIA BARIÁTRICA - OBESIDADE - PARTE AUTORA QUE AGUARDA HÁ MAIS DE 1 ANO PARA REALIZAÇÃO DA CONSULTA EM CIRURGIA BARIÁTRICA - AUSÊNCIA DEMORA EXARCEBADA - **1.500 PESSOAS OPERADAS EM 4 MESES E 300 OPERADAS EM 2 MESES** - INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADORA DE ILEGALIDADE APTA A AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, in fine, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5073077-45.2024.4.02.5101

510015402701 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5073077-45.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: ELIETE MOREIRA SALAZAR AYRES (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)
RECORRENTE: FRANKLIN ROOSEVELT SALAZAR AYRES (REPRESENTANTE) (AUTOR)
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Em suma, a pretensão consiste na condenação dos réus na imediata realização de **Cirurgia Bariátrica**, por ser diagnosticada com **Obesidade grau 3 (E66)**, além de outras comorbidades como Diabetes Mellitus Insulino Requerente (E10) e Hipertensão Arterial Sistêmica (I10), além de já fazer acompanhamento psicológico e nutricional.

O juízo indeferiu o pedido por considerar que a falta de vagas em hospitais públicos e a longa espera para a realização de cirurgias é um problema de saúde pública, não podendo o magistrado privilegiar um paciente em detrimento dos demais, que também aguardam internações e cirurgias. Eis os seus termos:

"(...)

Na presente hipótese, resta comprovado que a autora é portadora de Obesidade grau 3, demandando a realização de procedimento cirúrgico bariátrico (evento 1, anexo 2, p. 12/13).

Todavia, o acatamento das pretensões formuladas na inicial equivaleria a conferir à parte demandante - sem qualquer justificativa plausível - prerrogativa sobre diversas outras pessoas que se encontram na mesma condição clínica e cujo estado de saúde é igualmente crítico.

De início, verifica-se que a autora não apresentou nenhuma documentação médica atestando que haja risco eminente à vida pela não realização imediata da cirurgia. A escassa e desatualizada prova médica produzida pela parte autora não informa se existe algum risco de morte ou de agravamento do quadro clínico atual.

Não há nos autos qualquer prova de que haja urgência na realização do procedimento na autora, a justificar sua sobreposição aos demais pacientes em fila.

Nestes termos, não tendo o Poder Judiciário capacidade técnica para, sobrepondo-se à avaliação dos profissionais de saúde, decidir acerca da gravidade de quadros clínicos de pacientes, deve ser prestigiada a avaliação médica acerca da existência ou não de urgência que imponha a priorização da parte autora ante aos demais pacientes para os tratamentos demandados pelo seu quadro clínico.

Além disso, não houve negativa de tratamento médico à demandante, mas apenas sua inclusão nas vias ordinárias de atendimento o que, em seu entender, representa demora excessiva para a realização do procedimento cirúrgico.

Cabe observar que o tratamento a ser oferecido, bem como a priorização ou não de cada paciente leva em conta não apenas o critério cronológico, mas também outros fatores como sexo, idade e, sobretudo, gravidade do estado de saúde de cada um.

(...)

O acolhimento do pedido para a realização de cirurgia, inviabilizaria a de outro paciente, que pode apresentar quadro tão urgente quanto o da autora, não cabendo ao magistrado a escolha.

Garantir um tratamento em prol de um indivíduo significa a postergação de outros. Seria, desse modo, preocupante a atuação do Judiciário, que interviria indevidamente na Administração, sem o devido conhecimento sobre as prioridades, as enfermidades e a urgência de todos aqueles que aguardam ansiosamente a realização dos mesmos tratamentos e exames.

Não restam dúvidas que existe a necessidade de serem estabelecidos critérios administrativos que correspondam a uma melhora do atendimento às pessoas que necessitam de tratamentos de doenças de tal gravidade. Entretanto, a solução para tais entraves da Saúde Pública, não está no Judiciário, e sim nas políticas públicas de saúde, na qual o judiciário só pode intervir, para buscar a sua efetivação, o que não é o caso dos autos.

(...)"

A parte autora, por meio da DPU, apresentou recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Quanto à legitimidade dos 3 entes da federação, ela advém da Constituição Federal pela forma como idealizado o SUS, e da Lei 8.080/90, em seu artigo 6º, inciso I, alínea d, que prevê expressamente que estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. O mesmo diploma legal prevê, em seu artigo 9º, que a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) **será exercida em cada esfera de governo por órgãos distintos, sendo no âmbito da União a cargo do Ministério da Saúde, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente e no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente, devendo, portanto a responsabilidade ser repartida entre as três autoridades supra mencionadas.**

Especificamente quanto à União, existe inclusive um enunciado das Turmas:

Enunciado 43 TR-SJRJ - A União é parte legítima nas demandas que visem assegurar o direito às prestações do Sistema Único de Saúde - SUS.

Trata-se de Autora, de 47 anos de idade, com diagnóstico de obesidade grau 3 apresentando limitação funcional devido à ruptura do manguito rotador, aguardando resolução do caso de obesidade para continuidade do tratamento ortopédico (evento 1, ANEXO2, Páginas 12 e 13), solicitando o fornecimento de cirurgia bariátrica (evento 1, INIC1, Página 6).

Conforme parecer NAT do evento 62, PARECER1, considerando relato de falha no tratamento clínico, **a avaliação para cirurgia bariátrica está indicada e é imprescindível ao manejo do quadro clínico da Autora - obesidade grau 3** (evento 1, ANEXO2, Página 12). Além disso, **está coberta pelo SUS**, no que toca aos seguintes procedimentos: consulta médica em atenção especializada, acompanhamento de paciente pré-cirurgia bariátrica por equipe multiprofissional, gastroplastia c/ derivação intestinal; gastroplastia vertical c/ banda; gastrectomia com ou sem desvio duodenal, gastrectomia vertical em manga (Sleeve) e cirurgia bariátrica por videolaparoscopia. Ainda segundo o NAT, **a parte já foi inserida na plataforma do Sistema Estadual de Regulação - SER há 1 anos**, onde foi localizada solicitação de Consulta - ambulatorio 1ª vez - cirurgia bariátrica (Adulto), CID: Obesidade, **solicitada em 05/02/2024, pela Clínica da Família Medalhista Olímpico Mauricio Silva**, classificação de risco: **Amarelo - prioridade 2**, situação: em fila, **posição: 590º (informações de dezembro de 2024)**.

Esta Relatoria consultou o referido site em 10/02/2025. **Consta que a autora está na posição 289º (www.painel.saude.rj.gov.br)**, ou seja, aparentemente, **300 pessoas que estavam na sua frente na fila já foram tratadas em 2 meses**:

Cns	Solicitacao Id	Iniciais Nome	Data Nascimento (Dia do Mês)	Data Nascimento (Mês do Ano)	Data Nascimento (Ano)
Pesquisar Cns	5240429	Pesquisar Iniciais Nome	29	abril	1976

Rank	Solicitacao Id	Dt Solicitacao	Nome Paciente	Cns	Data Nascimento	Tipo Recurso	Recurso
289	5240429	05/02/2024 - 16:00		791408649058735	29/04/1976	CONSULTA	Ambulatorio 1ª vez - Cirurgia Bariátrica (Adulto)

Nesses termos, a Terceira Seção Especializada do E. TRF-2ª Região pacificou entendimento, segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário intervir em filas organizadas pela Administração Pública para a realização de procedimentos médicos, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Assim restou ementada a decisão:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO À SAÚDE. ART. 196, CF. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. ISONOMIA. RESPEITO À FILA ADMINISTRATIVAMENTE ORGANIZADA. 1. O direito à saúde implica para o Poder Público o dever inescusável de adotar providências necessárias e indispensáveis para a sua promoção, estabelecidas de forma universal e igualitária. Nesse contexto jurídico, se o Poder Público negligencia no atendimento de seu dever, cumpre ao Poder Judiciário intervir, num verdadeiro controle judicial de política pública, para conferir efetividade ao correspondente preceito constitucional. 2. Todavia, o acesso ao referido direito deve ser compatibilizado com o princípio da isonomia, de forma a não garantir privilégios àqueles que procuram o Judiciário em detrimento dos que aguardam por tratamentos e cirurgias de acordo com a fila administrativamente estabelecida. Assim, não cabe ao Judiciário administrar hospitais, estabelecendo prioridades de natureza médica. Precedentes. 3. Dessa forma, cabe à Administração Pública, mediante exame com base em critérios técnicos, aferir a possibilidade de internação no INCA ou em qualquer outro hospital da rede pública, respeitando a fila administrativamente estabelecida. 4. Por outro lado, é inviável, em um quadro insatisfatório, socializar o custeio de internação em rede hospitalar privada. Do mais, o deferimento do pedido, nesta hipótese, também representaria verdadeira preterição aos pacientes que aguardam na fila de espera. 5. Embargos infringentes conhecidos e providos. (TRF2, EAC 201151014901233, José Antônio Lisboa Neiva, TERCEIRA SEÇÃO ESPECIALIZADA, E-DJF2R 02/10/2012).

Por outro lado, o artigo 196 da Constituição Federal obriga o Poder Público a garantir o direito dos cidadãos à saúde, mediante políticas sociais e econômicas.

Com efeito, **não é dado ao Judiciário se imiscuir na alteração da lista de espera que é elaborada pelos setores competentes**, mormente considerando-se o grau de urgência aferido por quem de direito, sob pena de implicar prejuízo ao direito de outros pacientes que igualmente estão na lista de espera, e que podem apresentar quadro, inclusive, mais grave do que o da autora.

Portanto, é possível a intervenção judicial para garantir este direito ao cidadão, **quando houver falha do Estado**.

Nesses termos, em caráter de orientação, o FONAJS/CNJ, em suas Jornadas de Direito da Saúde, estabeleceu a baliza de que **a espera maior do que 180 dias para cirurgias eletivas indicariam a ineficiência administrativa** e, portanto, falha da política pública de modo a autorizar intervenção judicial a fim de garantir do direito fundamental à saúde integral:

ENUNCIADO Nº 93 Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

Em sentido semelhante, o TRF desta 2ª Região teve oportunidade de decidir que caberia ao Judiciário garantir o direito à saúde por meio da obrigação de tratamento indispensável para a melhora da qualidade de vida do paciente da rede pública de saúde, caso

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1 - **O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo Regimental na Suspensão da Tutela Antecipada nº 175, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a possibilidade de, após a análise minuciosa das circunstâncias de cada caso concreto e a realização de juízo de ponderação, o poder judiciário garantir o direito à saúde por meio do fornecimento de medicamento ou tratamento indispensável para o aumento de sobrevida e a melhoria da qualidade de vida do paciente da rede pública de saúde.** 2 - O artigo 196, da Constituição Federal, não consubstancia mera norma programática, incapaz de produzir efeitos, não havendo dúvidas de que obriga o poder público a garantir o direito à saúde mediante políticas sociais e econômicas, bem como a exercer ações e serviços de forma a proteger, promover e recuperar a saúde. 3 - No presente caso, quando do ajuizamento da demanda, a parte autora, portadora de neoplasia maligna mamária (fls. 27/36), apresentava quadro clínico grave, necessitando, urgentemente, de procedimento cirúrgico e tratamento oncológico. 4 - **Verifica-se, portanto, que andou bem o magistrado de primeiro grau que, ante a urgência do caso posto sob sua apreciação, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o Hospital Universitário Antonio Pedro - HUAP, da Universidade Federal Fluminense - UFF, providenciasse a internação e realização de procedimento cirúrgico da parte autora, com a manutenção do tratamento oncológico após a realização do procedimento cirúrgico, o que, posteriormente, foi confirmado por meio de sentença.** 5 - Restringindo-se o papel do poder judiciário à determinação de cumprimento da prestação devida, é o caso, pois, de se conferir efetividade à garantia do direito à saúde, norma constitucional cuja aplicabilidade é plena e imediata. 6 - Incabível a indenização por danos morais pleiteada pela parte autora, uma vez que o sofrimento narrado é inerente à sua condição de saúde, capaz de fragilizar qualquer pessoa que se veja acometida da mesma doença, não se vislumbrando qualquer ato que enseje violação à dignidade da parte autora a justificar a condenação do ente público ao pagamento de uma indenização. 7 - Para início do tratamento oncológico, devem ser levadas em consideração não somente as condições clínicas do paciente, como também os critérios e as normas para internação e atendimento, inclusive com inscrição em fila de espera, o que justifica a espera, por um período, para o início do tratamento, sobretudo quando há peculiaridades como no presente caso, em que a parte autora possui doença pulmonar obstrutiva crônica, o que acarreta um quadro clínico mais delicado. 8 - Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos. (TRF-2 - APELRE: 201451670009243 RJ, Relator: Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, Data de julgamento: 14/10/2014, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 22/10/2014)

No caso concreto, embora o prazo de 180 dias tenha sido ultrapassado, não se pode concluir pela falha administrativa, tendo em vista que a fila de espera está progredindo, ainda que não na velocidade esperada pela autora: em consulta realizada em **03 de setembro de 2024** pela CRLS, a posição da autora era a **2108º** (evento 1, ANEXO2, fl. 21); na consulta realizada pelo NAT em **29/12/2024**, **590º** (evento 62, PARECER1, fl. 4); e, em **fevereiro de 2025**, **289º**. Ou seja, **em um espaço de 4 meses ano passado, aproximadamente 1.500 pessoas foram a princípio operadas e, em 2 meses este ano, 300 o foram.**

Portanto, o caso é de **deferência ao mérito administrativo na alocação da fila conforme os recursos disponíveis**, pois não restou demonstrada que a atuação administrativa padece de ilegalidade, de modo a justificar a intervenção do Judiciário, haja vista que, em que pese o período de espera para realização da consulta/cirurgia, a fila está progredindo e, nos últimos meses, de forma mais acelerada.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA**, para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Condene a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, in fine, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa.